

Werkvertrag und andere | BuRe2

Zusammenfassung

1. WERKVERTRAG

Verträge auf Arbeitsleistung (Nominatverträge)

- Werkvertrag:
 - Bei einem Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer, gegen Bezahlung ein Werk für den Besteller herzustellen.
 - Merkmale Werkvertrag:
 - Im Zentrum der Leistung steht das Werk
 - Es ist der **Erfolg geschuldet**
 - Unternehmer verwendet i.d.R. eigene Arbeitsmittel
 - Einmalige Leistungserbringung

Erfolg geschuldet : Wie ist nicht relevant. Dagegen im Arbeitsvertrag geht es um die sorgfältige Arbeit.

Art. 363 OR

Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung.

- Der Werkvertrag kann formfrei geschlossen werden.
- Gegenstand eines Werkvertrages kann die Erstellung aber auch die Veränderung (z.B. Reparatur, Bearbeitung, Veredelung) einer Sache sein.
- Bspw.: Tuning, Herstellung eines Eherings, Haarschnitt, Hausbau, Anfertigen eines Möbelstücks, Bauplan des Ingenieurs, Anzug nach Mass, Autoreparatur, Aufbau einer umfassenden und «massgeschneiderten» IT- Landschaft

Höhe der Vergütung

- **Fixpreis** nach Art. 373 Abs. 1 OR
 - Wurde eine bestimmte Vergütung vereinbart, gilt diese grundsätzlich unabhängig vom Aufwand des Unternehmers (+ oder -). Nur bei **ausserordentlichen unvorhersehbaren Umständen**, welche die Fertigstellung des Werkes hindern oder übermässig Erschweren, kann der Richter nach seinem Ermessen eine Erhöhung des Preises oder die Auflösung des Vertrages bewilligen (Art. 373 Abs. 2 OR).
 - Änderungswünsche des Bestellers, Verletzung von Mitwirkungspflichten des Bestellers, Wassereinträge, Stürme, Erdbeben, Radioaktivität oder einschneidende behördliche Massnahmen.

Keine oder nur ungefähre Preisvereinbarung nach Art. 374 OR

- Fehlt im Vertrag eine Vereinbarung über die Vergütung oder ist sie sehr unbestimmt, so wird der Werklohn nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt.
- **Überschreitung des Kostenansatzes** nach Art. 375 OR: Wird ein mit dem Unternehmer verabredeter ungefährender Ansatz ohne Zutun des Bestellers unverhältnismässig überschritten, so hat dieser sowohl während als auch nach der Ausführung des Werkes das Recht, vom Vertrag zurückzutreten (Art. 375 Abs. 1 OR). Als Faustregel gilt eine Überschreitung von 10 %.
- Bei Bauten, die auf Grund und Boden des Bestellers errichtet werden, kann dieser eine angemessene Herabsetzung des Lohnes verlangen oder, wenn die Baute noch nicht vollendet ist, gegen billigen Ersatz der bereits ausgeführten Arbeiten dem Unternehmer die Fortführung entziehen und vom Verträge zurücktreten (Art. 375 Abs. 2 OR).

Vergütung nach der SIA - Norm 118:

- Enthält Regeln betreffend Abschluss, Inhalt und Abwicklung von Verträgen über Bauarbeiten.
- Ist nur anwendbar, wenn die Vertragsparteien ihre Übernahme ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart haben.
- Vergütung: **Einheitspreis** nach Art. 39 SIA-Norm 118 (Bestimmte Vergütung für einzelne Leistungen mal die Stückzahl); **Globalpreis** nach Art. 40 SIA-Norm 118; (Pauschalpreis mit Teuerungsabrechnung s. preisänderungen infolge teuerung - sia | schweizerischer ingenieur- und architektenverein); **Pauschalpreis** nach Art. 41 SIA-Norm 118 (fester Geldbetrag ohne Teuerungsabrechnung); **Regiepreis** nach Art. 44 ff. SIA-Norm 118 (Vergütung nach Aufwand)

Folgen bei Verletzung von vertraglichen Pflichten:

- Bei Mängelhaftung nach Art. 367ff. OR (Art. 364 Abs. 1 OR ist für die Beurteilung des Verschuldens heranzuziehen)
 - Der Unternehmer muss gemäss Art. 368 OR verschuldensunabhängig für Werkmängel einstehen.
 - Die Ausübung der Mängelrechte ist aber an folgende Voraussetzungen geknüpft:
 - Werk ist bei Ablieferung mangelhaft (Abweichung Ist- von der Soll-Beschaffenheit)
 - Besteller erfüllt Prüf- und Rügeobliegenheit
 - Der Besteller kann Mängelrechte nur geltend machen, wenn er das Werk weder stillschweigend noch ausdrücklich genehmigt hat (Art. 370 Abs. 1 OR).
 - Eine stillschweigende Genehmigung wird fingiert, wenn der Besteller die Prüfung des abgelieferten Werkes oder die Anzeige von Mängeln gegenüber dem Werkunternehmer nicht rechtzeitig vornimmt.
 - Rechtzeitig ist die Rüge gemäss Art. 367 Abs. 1 OR, wenn sie nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich erfolgt ist.
 - Bei versteckten Mängeln genügt es, wenn der Mangel sofort nach dessen Entdeckung gerügt wird.

Es liegt keiner der folgenden Ausschlussgründe vor:

- Der Mangel wird durch den vom Besteller gelieferten Stoff oder seinem Baugrund verursacht und der Unternehmer kommt rechtzeitig seiner Anzeigepflicht nach.
- Nach Art. 369 OR sind die Mängelrechte ausgeschlossen, wenn der Besteller unsachgemässe Weisungen zur Ausführung des Werkes erteilt hat. Dieser Ausschluss gilt nur dann, wenn der Unternehmer den Besteller auf die unsachgemässe Ausführung aufgrund einer solchen Weisung aufmerksam gemacht hat.
- Die Gewährleistung wurde nicht wegbedungen (Beachte die Schranken nach Art. 100 OR und Art. 199 OR).
- Der Anspruch ist nach Art. 371 OR nicht verjährt.

– Art. 371 OR

¹ Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängel des Werkes verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach der Abnahme des Werkes. Soweit jedoch Mängel eines beweglichen Werkes, das bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.

² Die Ansprüche des Bestellers eines unbeweglichen Werkes wegen allfälliger Mängel des Werkes verjähren gegen den Unternehmer sowie gegen den Architekten oder den Ingenieur, die zum Zwecke der Erstellung Dienste geleistet haben, mit Ablauf von fünf Jahren seit der Abnahme des Werkes.

³ Im Übrigen kommen die Regeln für die Verjährung der entsprechenden Ansprüche des Käufers sinngemäss zur Anwendung.

Seit Januar 2026

Die Änderung des Obligationenrechts (OR) vom 20. Dezember 2024 sieht wichtige Anpassungen und Verbesserungen für die **rechtliche Stellung der Bauherren und Immobilienkäufer bei Baumängeln** vor. So kann die Bauherrschaft ihre Rechte künftig einfacher wahrnehmen, wenn Bauunternehmer ihre Arbeit mangelhaft erledigen. Namentlich werden die **Rügefristen** für offene und versteckte Mängel auf neu 60 Tage seit Ablieferung des Werks bzw. Entdeckung des Mangels verlängert. Diese Fristen können vertraglich nicht verkürzt werden. Ausserdem kann das **Nachbesserungsrecht für Baumängel vertraglich nicht mehr ausgeschlossen** werden. Das soll nicht nur bei Bauwerkverträgen gelten, sondern auch beim Kauf von Grundstücken mit Neubauten, die noch zu errichten sind oder die innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem Verkauf erstellt wurden.

Gesetzliche Grundlagen

Art. 219^a OR Kaufvertrag

II. Mängelrüge, unentgeltliche Verbesserung und Verjährung

¹ Die Frist für die Mängelrüge beträgt beim Grundstückskauf 60 Tage. Mängel, die bei der übungsgemässen Untersuchung nicht erkennbar waren, sind innert 60 Tagen nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Vereinbarung kürzerer Fristen ist unwirksam.

² Der Käufer eines Grundstücks mit einer Baute, die noch zu errichten ist oder weniger als zwei Jahre vor dem Verkauf neu errichtet wurde, kann auch unentgeltliche Verbesserung verlangen. Dieser Anspruch untersteht den Bestimmungen über den Werkvertrag.

³ Die Ansprüche des Käufers wegen Mängeln des Grundstücks verjähren mit Ablauf von fünf Jahren nach dem Erwerb des Eigentums. Die Verjährungsfrist kann nicht zu Lasten des Käufers abgeändert werden.

Art. 367

4. Haftung für Mängel
a. Feststellung der Mängel

¹ Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen.

^{1bis} Die Frist für die Mängelrüge beträgt bei einem **unbeweglichen Werk** 60 Tage. Die Vereinbarung einer kürzeren Frist ist unwirksam. Dasselbe gilt für die folgenden Mängel eines Werks, die die Mangelhaftigkeit eines unbeweglichen Werks verursacht haben:

- a. Mängel eines beweglichen Werks, das bestimmungsgemäss in das unbewegliche Werk integriert worden ist;
- b. Mängel eines Werks, das von einem Architekten oder Ingenieur erstellt und bestimmungsgemäss als Grundlage für die Erstellung des unbeweglichen Werks verwendet worden ist.²⁵⁶

² Jeder Teil ist berechtigt, auf seine Kosten eine Prüfung des Werkes durch Sachverständige und die Beurkundung des Befundes zu verlangen.

b. Recht des Bestellers bei Mängeln

Art. 368

¹ Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Verträge ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern.

² Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Verträge minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen. Im Falle der unentgeltlichen Verbesserung gilt Artikel 366 Absatz 2 sinngemäss.²⁵⁷

^{2bis} Eine zum Voraus getroffene Verabredung, wonach der Anspruch auf unentgeltliche Verbesserung eingeschränkt oder ausgeschlossen wird, ist ungültig, wenn der Mangel eine Baute betrifft.²⁵⁸

³ Bei Werken, die auf dem Grund und Boden des Bestellers errichtet sind und ihrer Natur nach nur mit unverhältnismässigen Nachteilen entfernt werden können, stehen dem Besteller nur die im zweiten Absatz dieses Artikels genannten Rechte zu.

Werkvertrag

- Folgen bei Mängeln bei und nach der Ablieferung des Werks (Mängelhaftung):
 - **Wandelung** (Art. 368 Abs. 1 OR): Die Wandelung kann erklärt werden, wenn das hergestellte Werk entweder an erheblichen Mängeln leidet oder so sehr vom Vertrag abweicht, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder ihm nicht zugemutet werden kann, das Werk anzunehmen. Ist das Werk mit dem Grundstück des Bestellers fest verbunden, besteht das Recht zur Wandelung nur, wenn die Beseitigung nicht mit unverhältnismässigen Nachteilen verbunden ist. Hierbei ist die Kosten-Nutzen-Relation entscheidend.
 - **Minderung** (Art. 368 Abs. 2 OR): Der Umfang der Minderung ist nach der relativen Methode zu berechnen. Danach ist die volle Vergütung in dem Verhältnis zu kürzen, in dem der Wert des Werkes im mangelfreien Zustand zum Wert des mangelhaften Werkes steht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann vermutet werden, dass der Minderwert identisch mit den Kosten ist, die entstehen würden, wenn der Besteller die Mängel durch einen Dritten beseitigen lassen würde. (Ersatzvornahme)
 - **Nachbesserung** (Art. 368 Abs. 2 OR): Die Nachbesserung kann verlangt werden, sofern diese möglich ist und dem Werkunternehmer nicht übermässige Kosten verursacht. Die Nachbesserungskosten sind dann übermässig, wenn sie zum Nutzen, den die Mängelbeseitigung dem Besteller bringt, in einem Missverhältnis stehen, d.h. die Nachbesserungskosten unverhältnismässig hoch wären.
 - **Schadenersatz**: Kumulativ zur Wandelung, Minderung oder Nachbesserung kann beim Vorliegen von vermutetem Verschulden gemäss Art. 369 Abs. 1 und 2 OR Schadenersatz verlangt werden.
- Bei Verzug (Art. 366 OR sowie 102 ff. OR)
 - Befindet sich der Unternehmer im Verzug, so kann der Besteller vorzeitig vom Vertrag zurücktreten (Gestaltungsrecht).
 - Falls die Fertigstellung des Werkes unmöglich wird s. Art. 97 ff. OR.
 - Unter folgenden Voraussetzungen kann der Besteller gemäss Art. 366 Abs. 2 OR eine Ersatzvornahme durchführen:
 - Vorausssehbarkeit der mangelhaften oder sonst vertragswidrigen Herstellung des Werkes (Prognoseentscheidung)
 - Verschulden des Werkunternehmers (kein Selbstverschulden des Bestellers)
 - Angemessene Fristansetzung mit Androhung für den Fall der Unterlassung (Ersatzvornahme)
 - Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Bestellerin auch alternativ gemäss Art. 107 Abs. 2 OR vom Vertrag zurücktreten.

Art. 365 OR

¹ Soweit der Unternehmer die Lieferung des Stoffes übernommen hat, haftet er dem Besteller für die Güte desselben und hat Gewähr zu leisten wie ein Verkäufer.
(Sachgewährleistung)

² Den vom Besteller gelieferten Stoff hat der Unternehmer mit aller Sorgfalt zu behandeln, über dessen Verwendung Rechenschaft abzulegen und einen allfälligen Rest dem Besteller zurückzugeben.

³ Zeigen sich bei der Ausführung des Werkes Mängel an dem vom Besteller gelieferten Stoffe oder an dem angewiesenen Baugrunde, oder ergeben sich sonst Verhältnisse, die eine gehörige oder rechtzeitige Ausführung des Werkes gefährden, so hat der Unternehmer dem Besteller ohne Verzug davon Anzeige zu machen, widrigenfalls die nachteiligen Folgen ihm selbst zur Last fallen. (Orientierungspflicht)

Art. 377 OR

Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten.

2. AUFTRAG

Verträge auf Arbeitsleistung (Nominatverträge)

• Auftrag:

- Der Beauftragte übernimmt bei einem Auftrag die Verpflichtung, gewisse Geschäfte und Dienste im Interesse des Auftraggebers zu tätigen.

• Merkmale Auftrag:

- Im Zentrum steht das **sorgfältige Tätigwerden**
- Der **Erfolg ist nicht geschuldet**
- **Treueverpflichtung** des Beauftragten
- Besonderes Vertrauensverhältnis
- Selbständige Stellung des Beauftragten

• Überblick über die im OR geregelten Auftragsarten:

- Einfacher Auftrag (Art. 394 ff. OR)

bei Arbeitsvertrag gibt es auch spezielle wie Lehrvertrag und Einzelarbeitsvertrag.
Hier auch spezielle neben dem einfachen Auftrag.

- Auftrag zur Ehe- oder zur Partnerschaftsvermittlung: Wer einen Auftrag zur Ehe- oder zur Partnerschaftsvermittlung annimmt, verpflichtet sich, dem Auftraggeber gegen eine Vergütung Personen für die Ehe oder für eine feste Partnerschaft zu vermitteln (Art. 406a OR).
- Der Kreditbrief und der Kreditauftrag: Der Kreditauftrag verpflichtet den Beauftragten, einem Dritten Kredit zu gewähren.
- Der Mäklervertrag: Durch den Mäklervertrag erhält der Makler den Auftrag, gegen eine Vergütung, Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuweisen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln (Art. 412 Abs. 1 OR).
- Der Agenturvertrag: Agent ist, wer die Verpflichtung übernimmt, dauernd für einen oder mehrere Auftraggeber Geschäfte zu vermitteln oder in ihrem Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen, ohne zu den Auftraggebern in einem Arbeitsverhältnis zu stehen (Art. 418a OR).

Art. 394

¹ Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.

- Kann formfrei geschlossen werden (s. aber besondere Ermächtigung nach Art. 396 Abs. 3 OR).
- Im Grundsatz hat der Beauftragte den Auftrag vertragsgemäss auszuführen. Zwar ist der Erfolg nicht geschuldet. Der Beauftragte ist aber verpflichtet einen solchen anzustreben und in diesem Sinn tätig zu werden.
- Gegenstand eines Auftrages kann jede beliebige persönliche Handlung sein. Voraussetzung für das Vorliegen eines Auftrages ist stets, dass es sich um ein Tätigwerden in fremdem Interesse handelt.
- Die dem Beauftragten übertragenen Geschäfte können Rechtshandlungsaufträge oder auch Tathandlungsaufträge sein. Auch ist der Auftrag ein Sammelbecken für alle Arbeitsleistungs- und Dienstleistungsverträge, welche nicht einem gesetzlichen Sondertypus entsprechen.
 - Bspw.: Medizinische Behandlung, anwaltliche Beratung, Termin bei einem Steuerberater, Finanzberatung oder Unternehmensberatung

Art. 398 OR

1 Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.

2 Er haftet dem Auftraggeber für **getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes.**

- Zwar wird die gleiche Sorgfalt wie von einem Arbeitnehmer erwartet. Die entsprechenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen dürfen aber nicht 1:1 übernommen werden. Ob der Beauftragte unsorgfältig gehandelt hat, beurteilt sich danach, ob ihm sein Handeln **unter Berücksichtigung der konkreten Umstände** gemessen am **fachspezifischen Durchschnittsverhalten** vorwerfbar ist.
- Allgemein besteht ein Verschulden des Beauftragten darin, dass er die Vertragsverletzung vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt hat. Fahrlässig handelt der Beauftragte, wenn er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt verletzt.

Schneider,Anwalt.. erhält Auftrag, wenn er nicht antwortet hat er Auftrag angenommen und muss sonst absagen. Er muss reagieren!

Artikel 97 : Schlecht und Nichterfüllung.

Bei Auftragsrecht keine besondere Bestimmung bei Vertragsverletzung (Fehler von treuhänder Steuererklärung, Arzttermin verpasst...). Da keine besondere Bestimmung gilt Artikel 87

Anwalt darf Fristen nicht verpassen, Anwalt kann auch sagen im Voraus, wenn er etwas nicht machen kann

- **Treuepflicht**
 - Im Rahmen der Treuepflicht muss ein Auftraggeber die Interessen seines Auftraggebers wahren. Der Beauftragte ist demnach bspw. verpflichtet, den Auftraggeber zu:
 - beraten (auch Anweisungen des Auftraggebers kritisch zu hinterfragen)
 - informieren (auch über Interessenskollisionen)
 - Informationen geheim zu halten
 - Auch sollte der Auftraggeber die Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften besitzen, um den Auftrag nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen zu können.

• Art. 400

1 Der Beauftragte ist schuldig, auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge derselben aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, zu erstatten.

Treuepflicht gehört auch zur Sorgfaltspflicht rein. Wenn Pflichten nicht erfüllt: Haftungsthema, z.B. Schadenersatz oder Genugung (Verletzung selisch), Geheimhaltung (Bankgeheimnis, Arzt) bis zu Gefängnisstrafe

Rechenschaft ablegen = auch Datenschutz: kann Arzt nach Unterlagen über sich fragen

Art. 404 OR

1. Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder gekündigt werden.
 2. Erfolgt dies jedoch zur Unzeit, so ist der zurücktretende Teil zum Ersatze des dem anderen verursachten Schadens verpflichtet.
- Zwingendes Kündigungsrecht
 - Eine Vertragsauflösung zur Unzeit liegt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung vor, wenn der Zeitpunkt der Kündigung besonders ungünstig ist und für den Vertragspartner besondere Nachteile mit sich bringt.

bei allem was unter Auftragsrecht fällt, ist es zwingendes Recht, deshalb keine Kündigungsfrist möglich.